

<59회 민사소송 기출문제 예시답안>

안녕하세요, 양진하 변리사입니다. 올해 2차 시험 보시느라 정말 고생 많으셨습니다. 문제길어도 그렇고 사실관계 파악에 있어서도 크게 어렵다고 느껴질 만한 문제는 없었으나, 문제4의 설문(1)과 같은 문제는, 민사소송 법리를 물어보는 문제라기보단 비법인사단 여부에 대한 실체적인 판례의 결론을 알고 있어야 하는 문제로 절차적인 법리에 대해 물어보는 민사소송법 시험에서 다소 출제 취지가 바람직하지 않다고 여겨지는 문제였습니다.

이번 시험에서도 중요했던 것은, 실전/콜라보GS에서 말씀드렸듯, 문제 사실관계가 있다 하여 무조건 관련 논점을 다 적고 보는 것이 아닌, 설문에서 물어보는 것이 무엇인지를 정확히 판단해서 거기에 맞는 논점만을 작성해야 한다는 것입니다. 문제 사실관계에 특정 논점이 보인다면 하여 단순히 적었을 때는 배점이 부여되지 않습니다. 그 구체적 의미는 이하 답안을 보면서 확인해보시기 바랍니다. 각 설문에 맞는 논점을 쓰는 것, 즉 위치설정이 시험에서는 가장 중요한 부분 중 하나입니다.

이하 예시답안의 목차를 첨부합니다.

모두 11월에 좋은 결과 있으시길 바랍니다.

궁금한 사항 있으시거나 수정했으면 하는 사항 등이 있으시면 jinha9806@daum.net으로 언제든지 메일 보내주시면 되겠습니다.

<문제 - 1>

I. 설문(1) - GRE 문제4와 동일

1. 문제의 소재
2. 기판력의 의의, 취지 및 주관적 범위
3. 객관적 범위 및 작용국면 - 수익자가 이미 승소확정판결 받은 경우
 - (1) 상대효
 - (2) 기판력
 - (3) 사안
4. 설문해결 - 기판력 저촉X

cf. 상대효 언급이 필수적임 (기판력 일반 법리로 해결No) -> 위치설정 문제

cf. 기판력의 발생 목차 생략 (설문에서 이미 화해권고결정의 '기판력'이라고 명시)

cf. 창설효 선결 언급 可

cf. 사해행위인지 여부 判例 불요

-> 사해행위인지 실체법적으로 판단하는 부분 (중요 판례X) + 문제에서 묻지도 않음

cf. 화해권고결정은 재판상 화해와 동일한 효력이 있으나, 이는 당사자의 의사에 의해 성립되는 재판상 화해와 달리 법원의 소송행위이므로 법적성질 및 기판력 발생여부 관련 논의와는 무관함. (이런 논점의 위치설정 혼동하는 것을 주의해야 함)

II. 설문(2) - GRE 문제4와 동일

1. 문제의 소재
2. 기판력 저촉여부 - X
 - (1) 判例 - key: 고유의 권리
 - (2) 사안
3. 권리보호이익 저촉여부 - X
 - (1) 원칙
 - (2) 예외
 - (3) 사안
4. 설문해결 - 乙주장 배척하는 판단

cf. 피보전채권 달리하는 경우 소송물 동일하다는 판례 기재 可, But 설문해결에 필수적이지X

-> 생략 가능 ([대.사.부.말.소]-소송물은 동일하고 공격방어방법만 달리하는 경우)

III. 설문(3) - 콜라보 2회 문제2 설문(2) 동일

1. 문제의 소재
2. 기판력의 의의, 취지 및 주관적 범위
3. 객관적 범위 및 작용국면

- (1) 신체상해에 따른 손해배상청구 - 학판검
- (2) 일부청구와 소송물 - 학판검
- (3) 일부청구와 기판력 - 학판검
- 4. 시적범위 및 차단효
- 5. 설문해결 - 적극적 손해 및 이에 대한 지연손해금 (기판력 저촉X)
- 위자료 및 이에 대한 지연손해금 (기판력 저촉O)

cf. 10점 배점이기에 학판검 간략 기재 -> Ex. 일부청구와 소송물/기판력 논의 합치기, 학설 및 판례 위주로 기재(검토 생략)

cf. 지연손해금은 실무상 같이 판결이 나오는 것으로, 적극적손해와 위자료만 나눠도 출제에도에 부합하고 지연손해금을 답안에 별도로 현출했는지 여부는 배점에 큰 영향X

<문제 - 2>

I. 설문(1) - 실전 6회 문제1 동일

- 1. 문제의 소재 - 반소의 법적성질 -> 예비적 반소임을 먼저 언급
- 2. 의의 및 심판방법
- 3. 이심 및 심판대상
 - (1) 이심
 - (2) 심판대상 - 학판검
 - (3) 사안 - 위법

cf. 인용될 경우 대비 -> 예비적 반소임을 캐치 (병합형태, 반소형태 구분하고 시작하는 것이 가장 중요)

cf. 제418조 언급 불요 -> 설문에서 '적법'하게 甲청구 인용했다고 나옴

II. 설문(2) - 실전 6회 문제1 동일 (점유권 본소에 대한 소유권 반소)

- 1. 문제의 소재
- 2. 반소의 적법요건 [상.절.사.동.공] -> 상호관련성에서 본소와 '대상'이 X토지로 동일
- 3. 점유권에 기한 본소에 본권에 기한 반소청구 가부 - 학판검
- 4. 항소심 반소
 - (1) 원고 동의 요부
 - (2) 심급이익 해할 우려 없는 경우
- 5. 설문해결 - 甲동의 있는 경우 적법

cf. 심급이익 해할 우려 없는 경우[확.인.변.비]에서 '비'에 해당하지 않음을 주의. 위 요건에 정확히 부합하는 사안이 아닌 바, 甲동의 있는 경우 적법할 것이라는 오픈형 결론으로 마무리

cf. 설문이 묻는 것에 대해 정확히 위치설정해서 작성해야 함. -> 설문(1)은 반소를 판단하지 않은 것의 위법성, 설문(2)가 반소의 적법성을 물어봄 -> 설문(1),설문(2)가 물어보는 것에 맞게 논점 위치설정 필수. 서로 논점 혼동해서 다른 설문에 적는 것 주의

<문제 - 3>

예비적 공동소송은 안에 표준판례 및 주요 쟁점들이 너무 많기에 실전GS 및 콜라보 GS에서 여러 번 강조한 문제입니다.

-> 실전 6회 문제4 설문(2), 실전 8회 문제3 설문(2), 콜라보 문제4 설문(1), 흐름 민사소송법 p.294 관련 判例에서 모두 출제

I. 설문(1)

1. 문제의 소재
2. 예비적 공동소송
 - (1) 의의 및 취지
 - (2) 허용여부
 - (3) 요건
 - (4) 사안 -> '법률적 평가'를 달리하는 케이스 (not 택일적 사실인정)
3. 심판방법 - 제70조 1항 및 제70조2항
4. 설문해결 - 불허(판단누락에 준하는 위법)

cf. 주위적 피고에 대해 '기각될 것을 대비하여' 예비적 피고에게 청구 -> 예공(not 통공)

cf. 주위적 청구 일부인용시 예비적 청구 판단 가부 논점X (이것은 객병에서의 논점)

cf. 위 심판방법에서 제70조2항 위주로 기술 (제67조를 준용하는 내용은 설문(2)에서 주논점)

II. 설문(2)

1. 문제의 소재
2. 甲의 소취하 가부
 - (1) 제70조1항 본문 및 단서 -> 개별적 소취하 가능
 - (2) 소취하의 요건 - '시기'와 '동의' 요건 검토 (시기: 판결확정 전, 동의: 상대방 동의 要)
 - (3) 사안 - 乙의 동의가 있을 경우 가능
3. 丙,丁부분의 항소심 심판대상 여부
 - (1) 예비적 공동소송의 심판방법
 - 1) 소송자료 및 진행의 통일
 - 2) 판결 및 상소의 통일
 - (2) 관련 判例 - 2015다242429
 - (3) 丙,丁지위 - 상소심 당사자
 - (4) 사안 - 전부 이심, 전부 심판대상
4. 설문해결 - 소취하 가능 / 丙,丁은 항소심 당사자로서 항소심 법원의 심판대상이 됨

cf. 예비적 공동소송은 필수적 공동소송이나 독당참과 달리 '항소심 당사자'와 관련된 견해대립 없이 통설,判例임. 관련 학판검 기재 불요

cf. 배점상 67조 심판방법 자세히 서술함

III. 설문(3)

1. 문제의 소재
2. 주위적 피고 乙에게 효력이 미치는지 여부
 - (1) 심판방법 - 설문(2)에서 언급했기에 간략 서술
 - (2) 사안 - 乙에게 효력이 미치고 乙은 항소심 당사자
3. 예비적 피고 丁에게 효력이 미치는지 여부
 - (1) 丙, 丁간의 관계 - 공유자이기에 통상공동소송
 - (2) 乙, 丁간의 관계 - 예비적 공동소송 관계로 필수적 공동소송 준용
 - (3) 사안

丙, 丁은 통상공동소송 관계로 원칙적으로는 분리확정될 수 있으나, 乙이 항소심의 심판대상이 됨으로써 丁과 합일확정이 요구되는 바, 丁 부분도 심판대상이 되고 丁은 항소심 당사자.
4. 설문해결 - 乙, 丁모두에게 항소의 효력이 미침.

cf. 근거 判例 - 2009다43355

cf. 예비적 공동소송 관계이므로 전원이 상소심 심판대상이 될 것이나, 丙, 丁간에는 원칙적으로는 통공이기에 분리확정된다는 것을 알고 있음을 보여주기 위해 선결적으로 언급.

cf. 丁에 대해 통상공동소송 관계로 분리확정된다고 썼더라도 '수정이론'은 논점으로 작성하면 안됨을 실전GS때 여러 번 강조함.

cf. 위 판례의 결론은 모든 청구 부분이 심판대상이 되는 것으로 보았으나, 제한된 시험시간 내에서 丙, 丁간의 관계에 대해서만 판단했을 경우 통상공동소송으로 문제를 풀이했을 가능성도 충분히 있음 -> 다만 통상공동소송으로 행여 보았더라도, '수정이론'과 같이 설문해결과 무관한 부분까지 쓰는 것에서 시간 허비가 너무 되는 것만 주의. (배점에 고려X)

<문제 - 4>

I. 설문(1) - 콜라보 8회 문제2 설문(1) 유사 (당사자능력 문제)

1. 문제의 소재
2. 당사자능력의 의의 및 종류 -> 법인X, 비법인사단인지를 검토
3. 비법인사단의 판단기준
(1) 일반적 기준[조.다.단.단]

判例는 사단성을 가지는 규약과 이에 근거한 대표자를 두는 등 조직을 갖추고 기관의 의결이나 업무집행방법이 다수결의 원칙에 의해 행해지며 구성원의 가입,탈퇴와 관계없이 단체가 존속되고 단체로서 주요사항이 확정되는 경우 비법인사단으로 본다.

(2) 사안 - key: 사단의 실질 -> 문제 사실관계가 자세하지 않은 바 오픈형 결론

4. 비법인사단인 경우

대표자 또는 관리인이 있다면 당사자능력 구비(제52조)

5. 조합인 경우

(1) 조합의 당사자능력 인정여부 - 학판검

(2) 사안 - X

cf. 중요한 것은 위 설문은 당사자능력 문제이고, 기타 당사자적격, 소송능력, 변론능력 등을 쓰는 경우 답안지 인상에 안 좋아질 수 있다는 것 -> 위치설정 문제

cf. 노인요양센터 판례 (2018다227865)를 타겟으로 하여 낸 듯 하나, 이렇게 비법인사단임을 단순히 인정하지 않았다는 판례 결론을 알고 있느냐 몰랐느냐, 이런 실체법적 판단을 한 판례를 암기하고 있어야 하는 것이 출제의도라고 보기 어려움 (실제 판례도 노인요양센터가 노인요양시설의 명칭에 불과한지 비법인사단/재단의 실체를 갖추었는지를 심리해야 한다고 봄)

-> 위 답안과 같이 수험적합적으로 비법인사단임을 판단하는 기준을 정확히 서술하고 그 기준을 충족하느냐 못하느냐에 따라 이후 당사자능력 인정 여부에 대한 논의를 서술해나가면 충분할 것으로 보임. (조합에 관해서는 간략 서술해도 충분할 것으로 보임)

II. 설문(2) - 실전4회 문제2 설문(1), 콜라보4회 문제3 설문(1) 유사 (절차중단 문제)

1. 문제의 소재 [당.중.수.간]
2. 당사자지위의 당연승계 여부 - 학판검
3. 절차중단여부 [망.소.상.대]
4. 절차중단을 간과한 판결의 효력 - 학판검

cf. 甲의 사망사실을 간과했을 때의 판결 효력을 물었는 바 당사자능력 간과시의 견해대립 쓸 필요X -> 당사자능력 흠결 사실관계만 있다 해서 적는 것이 아닌, 문제에서 묻는 것이 무엇인지 정확히 읽고 설문해결하는 것이 중요함.